

1502139-11.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502139-11.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502139-11.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTHIAN DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

IVANILDO ALVES DA SILVA e CRISTHIAN DA SILVA foram denunciados por incursão no inciso II do § 2º do artigo 157 c.c inciso II do artigo 14, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta de 01h10min, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, altura do número 287, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, tentaram subtrair, para proveito comum, o veículo VW/Voyage 1.0, de cor branca, placas ABL-8E65, e outros bens de valor, pertencentes a Marciel Vieira de Sousa, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 115-6) e apresentaram resposta à acusação (fls. 122-3).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ou, ao menos, a fixação das penas no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão para o réu Ivanildo e a causa de diminuição da tentativa no grau máximo, além da fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-3), boletim de ocorrência (fls. 11-3) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogados, em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 09-10).

Sob o contraditório, Cristhian alegou que não conhece o corréu e no dia dos fatos foi em direção ao carro da vítima, pois estava chamando um uber para ir até a casa de sua mãe. No mais, não se recordou de detalhes, em razão de estar alcoolizado naquele dia (mídia digital).

Ivanildo, por sua vez, admitiu ter pedido dinheiro à vítima e, diante da negativa, exigiu o carro. Disse que estava com a mão no bolso e nem chegou a encostar no veículo. Afirmou, por fim, que Cristhian surgiu como passageiro (mídia digital).

As versões dos réus encontram-se totalmente isoladas do conjunto probatório.

A vítima, na fase inquisitiva, narrou que (sic) "é motorista de aplicativo UBER e teria estacionado seu veículo VW VOYAGE 1.0L MC4, branco, de placas ABL8E65 no endereço local dos fatos para esperar por uma nova "corrida" quando os dois indivíduos surgiram do nada, tendo IVANILDO se posicionado ao seu lado afirmando em tom ameaçador "nem tenta", colocando a mão na cintura denotando que estivesse armado, enquanto o outro indivíduo CRISTHIAN DA SILVA tentava abrir a porta do passageiro, instante em que a viatura da polícia militar passou pelo local e solicitou ajuda, sendo que por pouco não teve seu veículo roubado" (fl. 08).

Em juízo, reafirmou que um dos acusados parou do lado do seu veículo e pediu dinheiro, como se fosse morador de rua, momento em que o outro se posicionou do outro lado e tentou abrir a porta do carro. Ato contínuo, o primeiro, que estava do seu lado, disse para não reagir e levantou a camisa. Os suspeitos não concretizaram o roubo, pois, logo em seguida, uma equipe da polícia militar interveio. Esclareceu que não viu arma de fogo (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juizes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os policiais militares, na fase antejudiciária, historiaram que (sic) "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, qual seja, na Av. Governador Mário Covas Júnior, 287, Centro, Mauá/SP, por volta de 01h e 10min, quando vislumbraram uma

situação suspeita com dois indivíduos que cercavam o veículo VW VOYAGE 1.0L MC4, branco, de placas ABL8E65, ano 2019, modelo 2020, sendo que um deles forçava a porta do referido veículo. Desse modo estes milicianos ao se aproximarem do veículo, o motorista Sr. MARCIEL VIEIRA DE SOUSA, ora vítima, afirmou que os dois indivíduos tentaram subtrair seu veículo mediante grave ameaça. Assim, efetuaram a abordagem aos dois assaltantes, posteriormente identificados como IVANILDO ALVES DA SILVA e CRISTHIAN DA SILVA, sendo que IVANILDO tentou se esquivar saindo devagar do local, porém foi alcançado logo adiante. Ato contínuo, na revista pessoal dos suspeitos nada de ilícito foi encontrado" (fls. 04-7).

Durante a instrução, o policial militar Dailton reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido, confirmando ter visualizado os réus ao lado do veículo da vítima. Com a aproximação da equipe, cada um dos suspeitos foi para um lado, mas foram detidos. Informalmente, um deles disse que estava apenas pedindo dinheiro, enquanto o outro alegou que ia solicitar uma corrida de uber (mídia digital).

Da mesma forma, a prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O conjunto probatório produzido sob o contraditório, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares, autoriza o desate condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

A prova oral indica que os réus, previamente ajustados, participaram do delito, sendo que Ivanildo anunciou o roubo, enquanto Cristhian forçou a porta do passageiro, a fim de acessar o interior do veículo.

Não há que se falar em crime impossível. Com efeito, "não exclui a possibilidade de tentativa, respondendo o agente por ela, quando o meio é relativamente ineficaz, ou seja, quando há uma mínima possibilidade de atingir o resultado" (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 2005, pág. 185). Essa tem sido a orientação perfilhada pela jurisprudência (STJ, REsp nº 633.656, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp nº 555.268, rel. Min. Gilson Dipp; REsp nº 598.224, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; REsp nº 554.233, rel. Min. Laurita Vaz).

No caso concreto, o fato de a vítima estar trancada no interior do veículo não impede, em absoluto, a possibilidade de consumação do crime, que apenas não ocorreu devido à intervenção da equipe policial.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, estabelece-se a pena-base dos réus 1/6

acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (Cristhian - certidão de fls. 33-4 - proc. 1501011-24.2020 e Ivanildo - certidão de fl. 43 c/c informações de fl. 49 - proc. 0038034-84.2006), perfazendo 04 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações de Cristhian, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. Resp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na etapa intermediária, a pena de Ivanildo permanece inalterada, enquanto a pena de Cristhian sofre novo acréscimo de 1/6 pela reincidência (certidão de fls. 34-5 - proc. nº 1501740-16.2021), atingindo 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão para o réu Ivanildo, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, tentando roubar o veículo da vítima, e buscou falsear a verdade, a fim de isentar seu comparsa de responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida -recruto de votos precedentes-, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed.

Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Em que pese respeitável entendimento jurisprudencial em sentido diverso, tenho que a atenuante da confissão espontânea não deve ser aplicada, pois o apelante foi preso em flagrante no interior do terreno da unidade básica de saúde, na posse de ferramentas aptas à concretização do furto. Há incompatibilidade lógica entre prisão em flagrante e atenuação da pena pela confissão espontânea" (TJSP, Ap nº 1502232-08.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 17.10.22) g.n.

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a

confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTCRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão,

porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisum, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravos regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravos regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão

informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Note-se que não basta a confissão parcial para a incidência do disposto da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020). "A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Na última fase da dosimetria, em razão da causa de aumento do concurso de agentes, majoro as reprimendas em 1/3, atingindo 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa para o réu Cristhian e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o réu Ivanildo.

Na sequência, em razão da tentativa, observado o iter criminis percorrido - réus anunciaram o roubo e forçaram a porta do veículo da vítima - procede-se a

diminuição da pena em 1/2, definindo-se as condenações em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 08 dias-multa para o réu Cristhian e 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa para o réu Ivanildo.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, notadamente em razão dos péssimos antecedentes. Não fosse suficiente, o crime de roubo de veículo, bem de elevado valor, praticado em comparsaria, denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119). Regime mais brando é insuficiente para prevenção e reprovação da conduta. Nessa linha:

"Roubo qualificado - Corréu primário - Crime praticado com grave ameaça contra a pessoa e em concurso de agentes - Ação que abala a ordem pública e recomenda enérgica intervenção estatal - Regime fechado - Possibilidade - Recursos improvidos. [...] Por fim, o regime fechado para ambos era mesmo de rigor, a despeito da primariedade do corréu Kennedy e do pleito da Defesa, já que se trata de crime cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes, o que denota a periculosidade do roubador. Ações dessa natureza, ademais, causam abalo à ordem pública, cada vez mais atemorizada com o avanço da violência, a ponto de recomendar enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal de Justiça: "O regime prisional inicial fechado revela-se pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda". (Apelação nº 0017323-72.2017.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 28/03/2018). [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1504097-37.2018.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CRISTHIAN DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e 08 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu IVANILDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e 07 dias-multa, no unitário mínimo, ambos por incursão no inciso II do § 2º do artigo 157 c.c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Denego os apelos em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita (fl. 152).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA